

1500177-79.2021.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta de Oliveira Ferreira Lima

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... um dos verbos considera-se consumado o crime de tráfico de drogas.

Além disso, ainda que o acusado seja usuário de drogas, é comum usuários praticarem o tráfico para sustentar seu vício. Não há que se falar em desclassificação para o crime no artigo 28 já que pela quantidade e diversidade de droga apreendida, a finalidade da traficância ficou totalmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

2ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500177-79.2021.8.26.0574 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500177-79.2021.8.26.0574 Ctrl.724/2021

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial

(Flagrante) - 2185584/2021 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 18955603 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 1837/21/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2185584 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2185584 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1837/21/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 056/2021 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2185584/2021 - DISE- DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DA SILVA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

Vistos.

LUCAS DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 08 de julho de 2021, por volta das 22h20min, na Rua Fartura, nº 197, Parque Industrial Jurumirim, nesta Cidade e Comarca de Avaré, vendeu ao adolescente Richard da Silveira Soares, 01 porção de cocaína, pesando cerca de 0,71 grama, acondicionada em eppendorf, bem como trazia consigo, para entrega a terceiros, 07 (sete) outras unidades da mesma droga, acondicionadas de maneira idêntica, com peso

aproximado de 4,88 gramas; além de ter em depósito, com igual finalidade, na Rua Miguel Chibane, nº 431, Jardim Tropical, nesta cidade e Comarca, 02 (duas) porções de maconha, com peso aproximado de 7,60 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, laudo de constatação provisória de fls. 33/36 e laudo do exame químico toxicológico de fls. 86/90, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, o denunciado estava se dedicando ao tráfico de drogas nesta cidade e, na ocasião, estava na Rua Fartura, acompanhado do referido adolescente, a quem acabara de vender uma porção de cocaína.

Quando perceberam a aproximação de Policiais Militares, o menor colocou o eppendorf contendo cocaína na boca, enquanto o indiciado tratou de dispensar as sete porções da mesma droga, que ele trazia consigo.

Ocorre que suas ações foram percebidas pelos militares, que localizaram e apreenderam as porções de cocaína dispensadas ao solo. Em buscas pessoais, ainda foram apreendidos o eppendorf que o adolescente colocou na boca, além da quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que estava em poder do mesmo. Com o denunciado, os agentes localizaram R\$ 47,00 (quarenta e sete reais).

Ato contínuo, em busca realizada na residência dele, os patrulheiros logram êxito em localizar as 02 (duas) porções de maconha.

Notificado o réu (fl. 112), foi oferecida a defesa preliminar do réu, no prazo legal (fl. 132).

A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2021 (fl. 101), sendo que o réu foi citado (fl. XX).

O processo foi instruído com a inquirição de três testemunhas de acusação e interrogado o réu ao final.

Em debates orais, o Ministério Público postulou a condenação do réu nos exatos termos da exordial acusatória, ao passo que a Defesa Técnica requereu a absolvição do réu, diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando em caso de condenação.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada contra um Réu, por ter praticado a conduta descrita nos artigos 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Não há que se falar em ilicitude da prova, já que a busca pessoal e residencial se deram com a fundada suspeita sobre o acusado e situação de flagrância estava patente, não cabendo alegação de ilicitude, conforme se verá adiante.

Não cabe também a alegada falta de aviso de Miranda, eis que a conduta dos policiais é revestida da presunção de legitimidade, cabendo às Defesas a comprovação de que não houve o aviso de seus direitos. Além disso, conforme leciona o douto Desembargador Diniz Fernando, no voto da Apelação nº 0050998-

94.2015.8.26.0050, tal advertência, própria da tradição norte-americana é originada do caso Miranda vs. Arizona (384 US 436, 1966), consiste, em linhas gerais (pois varia de acordo com cada Estado norte-americano) em: "Você tem o direito de ficar calado, tudo o que disser pode e será usado contra você no Tribunal". Como aponta a doutrina constitucionalista: "Essas regras sobre a instrução quanto ao direito ao silêncio as chamadas Miranda rules hão de se aplicar desde quando o inquirido está em custódia ou de alguma outra forma se encontre significativamente privado de sua liberdade de ação:

'while in custody at the station or otherwise deprived of his freedom of action in any significant way'" 1 . Trata-se de aviso derivado do princípio da não autoincriminação (na fórmula latina, nemo tenetur se detegere), princípio este que, todavia, ganha contornos próprios na ordem jurídica brasileira, ao ser previsto no art. 5º, LXIII da CF: "o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado". Nesse sentido, o aviso quanto ao direito de permanecer em silêncio é aplicável ao interrogatório formal do réu, o que foi plenamente respeitado no caso em apreço,

como se depreende do precedente paradigma sobre a matéria, verbis: "Gravação clandestina de 'conversa informal' do indiciado com policiais. 3. Ilicitude decorrente - quando não da evidência de estar o suspeito, na ocasião, ilegalmente preso ou da falta de prova idônea do seu assentimento à gravação ambiental - de constituir, dita 'conversa informal', modalidade de 'interrogatório' subreptício, o qual - além de realizar-se sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial (C.Pr.Pen., art. 6º, V) -, se faz sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. 4. O privilégio contra a autoincriminação - nemo tenetur se detegere -, erigido em garantia fundamental pela Constituição - além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do art. 186 C.Pr.Pen. - importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência - e da sua documentação formal - faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em 'conversa informal' gravada, clandestinamente ou não" (STF, HC 80949, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 30/10/2001, g.n.). Esse entendimento do E. STF não destoa do que prevê a Convenção Americana de Direitos Humanos: Artigo 8º Garantias judiciais 1 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 573. 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: (...) g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; No mesmo sentido a doutrina processual penal: "O direito de calar também estipula um novo dever para a autoridade policial ou judicial que realiza o interrogatório: o de advertir o sujeito passivo de que não está obrigado a responder às perguntas que lhe forem feitas. Se calar constitui um direito do imputado e ele tem de ser informado do alcance de suas garantias, passa a existir o correspondente dever do órgão estatal a que assim o informe, sob pena de nulidade do ato por violação de uma garantia constitucional. O direito de silêncio é apenas uma manifestação de uma garantia muito maior, insculpida no princípio nemo tenetur se detegere, segundo o qual o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando do interrogatório" (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal, 11ª edição. Saraiva: São Paulo, 2014, p. 232).

Quanto à alegada quebra de cadeia de custódia, é certo que os laudos periciais de fls. 30/35 e 146/150 contém todas as numerações de lacre da droga e objetos apreendidos, sendo possível visualizar nas fotografias, não havendo embasamento para tal alegação.

A pretensão punitiva é procedente.

Assim, tem se por devidamente comprovadas materialidade e autoria.

A materialidade delitiva restou evidenciada através do auto de prisão flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls.19/22), auto de exibição e apreensão (fl. 23/24), fotos das drogas (fls.25/30), laudo de constatação (fls.33/36), laudo toxicológico (fls. 86/90), guia de depósito judicial (fl. 91), relatório policial final (fls. 92/94) e prova testemunhal.

A autoria igualmente se mostra evidente.

Os policiais militares ALEX MARTINS DE ALMEIDA e HERNANI MARIO SAUDINO relataram na fase policial, que em patrulhamento pelo local dos fatos depararam-se com o adolescente Richard e o jovem adulto Lucas. Em razão da fundada suspeita, consistente em no ato do jovem adulto esboçar jogar algo, realizaram a abordagem em ambos e constataram que o adolescente trazia consigo, na boca, um eppendorff de substância aparentando ser cocaína. Em seguida, verificando o local em que Lucas dispensou algo, encontraram alguns eppendorfs semelhantes ao que estava em posse do adolescente. Ao todo foram encontrados oito eppendorfs. Questionado, ele disse que a droga tinha sido adquirida de Lucas. Após, perguntaram a Luca se havia mais drogas em sua residência, no que ele negou. Contudo, diligenciaram até o endereço de Lucas e lá, franqueado por seu irmão, ingressaram e conseguiram localizar mais

duas trouxinhas de maconha. Em posse do adolescente havia R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e do adulto o valor de R\$ 47,00 (quarenta e sete reais). Em razão dos fatos deram voz de prisão a Lucas e conduziram as partes até o plantão policial (fls.02 e 04).

Em juízo, o policial Alex Martins de Almeida disse que no bairro Jurumirim, eram dois indivíduos, ele e o menor, quando o Lucas viu a viatura, dispensou algo ao solo, então abordaram. Na abordagem, nada encontrado. O menor estava com dificuldade para falar. Solicitou que ele abrisse a boca, encontraram no interior da sua boca eppendorfs aparentando cocaína. Indagado onde tinha adquirido, disse que tinha comprado do Lucas, disse que já havia comprado do Lucas outras vezes. Eles vinham da casa noturna Karin, sendo que lá efetuariam o comércio. No solo, encontraram 7 ou 8 eppendorfs idênticos ao encontrado com o menor. Indagado se tinha algo na casa, ele negou. Foram na casa, o endereço que ele deu como sua casa, encontraram duas porções de maconha. Seu irmão autorizou a entrada e disse que a casa seria de herança e que o Lucas usava um quarto esporádico, só para dormir, chegava tarde. O irmão negou ser proprietário da droga, disse ser do Lucas. O réu não conhecia pessoalmente mas tinham informações de um indivíduo com o nome dele praticando tráfico na casa noturna (gravação audiovisual).

No mesmo sentido, o policial Hernani Mario Saudino disse que em patrulhamento pelo local e se depararam com Lucas e o adolescente Richard. Ao ver a viatura, Lucas dispensou algo ao solo. Foram abordados com o adolescente um eppendorf em sua boca. No solo outros eppendorfs de cocaína. O adolescente indagado, disse que adquiriu com Lucas. Indagado se na casa haveria algo, negou. Na casa, o irmão de Lucas autorizou a entrada e encontraram duas porções de drogas, a qual o irmão disse ser do Lucas. Lucas confirmou a propriedade da droga toda. Não conhecia o réu. Os dois falaram que estavam vendendo as drogas no Karin para o pessoal que frequenta, as garotas de programa.(gravação audiovisual).

Na fase policial a testemunha de acusação RICHARD DA SILVEIRA SOARES disse que conhece Lucas porque residiu no mesmo bairro dele e na presente data encontrou-o na Travessa Cambará, próximo ao número 65 e resolveram sair juntos para "encontrar umas meninas no Karim", porém, não encontraram as meninas lá, quando estavam descendo a rua foram abordados pela polícia. Quando da abordagem, estava mascando um eppendorf vazio que tinha encontrado no chão da rua e, por estar olhando para os policiais, não presenciou o encontro das drogas. Tinha ciência que Lucas estava portando drogas, pois tinham combinado de usar drogas com as "meninas do Karim". Nunca respondeu nenhum ato infracional por drogas e desconhece se Lucas já foi preso ou não por drogas. Por fim, disse ser usuário de drogas. Em sua posse encontravam-se R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referentes ao recebimento de salário de seus serviços como instalador de janela veneziana (fl.05).

Na fase policial, o réu LUCAS DA SILVA PEREIRA disse que conhece o adolescente Richard há quatro anos e tinha consciência de sua idade. Na data dos fatos encontrou com Richard perto de sua residência e combinaram irem até o "Karim", local conhecido como Casa de Prostituição e usarem drogas juntos. No local usaram drogas com as moças. Após, resolveram sair e esperar as meninas voltarem, contudo, quando estavam na via foram abordados pela polícia militar e, quando ia colocá-las no bolso elas caíram. No momento da abordagem Richard mastigava algo, mas não sabia o que ele estava mastigando, vendo que era algo preto. Não avistou quando eles encontraram as drogas no chão. Após a abordagem foi conduzido para a sua residência, porém não ingressou e não acompanhou quando encontraram mais drogas e nem viu as drogas que foram encontradas e não se recorda de haver maconha em sua residência. Com relação ao dinheiro que estava em sua posse R\$ 47,00 (quarenta e sete reais), trata-se da sobra de dinheiro que tinha gasto no local, oriundo de sua atividade como servente de pedreiro. Não desejou avisar ninguém momentaneamente (fl. 08).

Em juízo, o réu Lucas da Silva Pereira disse que foi encontrado entorpecente com ele. Tinha ido comprar para usar. Comprou e estava descendo para ir embora, encontrou Richard que estava descendo. Quando chegou na esquina recebeu a abordagem. Falou que tinha oito entorpecente. Falou que tinha dinheiro. E foram no Richard. A droga não estava com Richard mas com o réu. A droga era para consumo

pessoal (gravação audiovisual).

Esse é o conjunto probatório dos autos.

A negativa apresentada pelo acusado vem refutada pela prova testemunhal e demais documentos carreados aos autos.

Pois bem.

Respeitado o entendimento da combativa defesa, essas provas são suficientes para ensejar o decreto condenatório.

Como se vê, ficou evidente que o réu praticou o delito a ele imputado como na denúncia.

Verifica-se, portanto, que os depoimentos dos policiais, demonstraram com clareza que o acusado estava praticando o delito de tráfico de drogas, bem como ficou demonstrado que sua prática visou a atingir criança ou adolescente.

Ainda nesse sentido, os policiais foram incisivos, coerentes e relataram os fatos com riqueza de detalhes. Todos estes elementos ainda devem ser aliados à presunção de veracidade que possuem por serem agentes públicos.

Assim, os seus depoimentos, por si só, permitem concluir pela existência do tráfico, sendo que sua prática envolveu ou visou a atingir adolescente.

Restou apurado que os policiais, estavam realizando patrulhamento de rotina, e perceberam que o acusado e o adolescente agiram em atitude suspeita, tendo em vista que os agentes perceberam que o acusado jogou algo, motivo pelo qual resolveram abordá-los.

Foi possível que os policiais encontrassem, em abordagem, oito eppendorfs contendo cocaína, sendo que um eppendorf encontrava-se na boca do adolescente. Os policiais ainda constataram que com o adolescente havia o valor de R\$ 150,00 e com o acusado o valor de R\$ 47,00.

O adolescente disse que foi Lucas quem lhe forneceu o entorpecente. Bem como ambos acabaram confirmando que vendiam a droga na boate Karin.

Ficou demonstrado que o acusado encontrava-se vendendo entorpecente ao adolescente, que quando avistou os policiais rapidamente colocou em sua boca o eppendorfs, já o acusado ao perceber a presença dos agentes jogou as drogas.

Destaca-se ainda, que foram encontradas dentro da casa do acusado, duas porções de maconha.

Tais fatos faz com que seja possível concluir, com tranquilidade e segurança, que o acusado cometeu o crime a ele imputado conforme descrito na denúncia.

Outrossim, verifica-se que, o laudo toxicológico de fls. 86/90 atestou a presença de cocaína e maconha, o auto de exibição e apreensão demonstram as drogas apreendidas e o dinheiro apreendido às fls.23/24, é possível ver nas fotos, as drogas apreendidas pelos policiais, e constatar que os eppendorfs possuem mesmas características, conforme demonstrado à fls.25/30, o que corrobora com toda a narrativa.

Deve ser ressaltado que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, até porque são agentes do Estado, investidos regularmente em sua função pública e está em perfeita sintonia com as demais provas existentes nos autos.

Nesse sentido: "TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial. (Apelação Criminal n. 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.)".

Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que as circunstâncias dos fatos, as drogas e valor em dinheiro apreendidos denotam o intuito mercantil, corroborados pelos depoimentos dos agentes, são suficientes a embasar o decreto condenatório, não sendo crível que tais pessoas mentissem apenas para prejudicar o

réu.

Quanto às teses defensivas não há que se falar em insuficiência probatória, diante das provas contidas nos autos e por tudo agora até exposto.

Ressalte-se que, o artigo 33 da lei de Drogas inclui "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.". E ainda que não tenha sido flagrada a situação de venda, a incidência de qualquer um dos verbos considera-se consumado o crime de tráfico de drogas.

Além disso, ainda que o acusado seja usuário de drogas, é comum usuários praticarem o tráfico para sustentar seu vício. Não há que se falar em desclassificação para o crime no artigo 28 já que pela quantidade e diversidade de droga apreendida, a finalidade da traficância ficou totalmente demonstrada.

Portanto, a condição de usuário não exclui a de traficante.

Contudo, a droga encontrada, aliada com a circunstância dos fatos, a maneira como foram encontrados os entorpecentes, a forma que estava embalado o ilícito, o dinheiro apreendido, denotam, às claras, que não se prestaria nem que a fizesse a posse para consumo ou destinação diversa que não a para o tráfico, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ficou devidamente demonstrado também, que a prática do tráfico envolveu ou visou atingir adolescente, de modo que faz-se mister a aplicação do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

A Lei Federal no 11.343/06, em seu artigo 40, inciso VI, confere uma maior reprovabilidade da ação, prevê aumento de pena para o traficante que, na prática do ato ilícito (tráfico) envolve ou visa atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

Não há nenhum outro elemento em contrário que diminua a certeza sobre a procedência do pedido condenatório.

Considero assim, provada a autoria dos delitos.

Deve-se destacar que na atual conjuntura social, o tráfico de entorpecentes é uma das principais infrações causadoras da destruição do lar familiar, bem como a que mais atormenta a sociedade.

De modo que, essa situação indica sem sombra de dúvidas a necessidade de se coibir tal conduta, visando a proteção e preservação da sociedade.

Não há que se cogitar na absolvição requerida pela defesa, pois os depoimentos dos policiais, foram harmônicos e coerentes.

Não há nenhum outro elemento em contrário que diminua a certeza sobre a procedência do pedido condenatório.

Resta claro do relato dos policiais, que a abordagem foi motivada pela suspeita de traficância, já que ao verem a viatura, o réu jogou o objeto ao solo, sendo posteriormente identificado como drogas. Inquestionável que a ação dos agentes da lei se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

De outro enfoque, faz parte da atividade policial exercer o poder de polícia, incluindo a pesquisa na busca da elucidação da autoria de crimes. E isso não se faz sem o diálogo com aquele que está na mira da investigação. Não quer dizer que toda vez que se obtenha, nesse encontro, uma confissão à primeira hora, se estará diante de uma afronta ao direito ao silêncio.

No mais, como apontado, é prescindível a cientificação do direito ao silêncio em conversa informal, como acontece em uma abordagem policial.

Seria um solene despropósito negar validade ao relato dos anteditos policiais, que, em audiência, reprisando as circunstâncias do flagrante, sabatinados nas reperguntas, não caíram em contradição, nem tiveram passagem alguma, da narrativa, neutralizada pelo contraditório e ampla defesa.

Insta, ainda, salientar que: "(...) A legalidade estrita orienta que, até prova definitiva em contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato

administrativo praticado pelo Poder Público (STF, RE n.º 75.567/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 20/11/1973, DJ de 19/4/1974, v.g.) (...)” (AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, STJ, j. 07/06/2017, DJe 20/06/2017).

Está consolidado que o testemunho dos agentes de segurança pública é de grande valia e não pode ser desconsiderado, inexistindo no caderno processual provas de que tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação fantasiosa e incriminando inocentes, não havendo razão para duvidar de sua palavra.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, que reafirma o entendimento recorrente da Corte sobre o tema: Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJe de 8-9-2011). Na mesma direção a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (Habeas Corpus 165561/AM, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 2/2/2016). (...) O depoimento dos policiais militares flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp nº 739749/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 19/5/2016).

O ingresso dos policiais militares na residência indicada pelo acusado, sem autorização judicial, não está eivado por qualquer mácula. Primeiramente, porque não há comprovação de que a entrada não foi permitida, e conforme palavra dos policiais, o irmão do acusado franqueou suas entradas.

De fato, não há qualquer menção nos autos de resistência ao ingresso dos agentes por parte dos residentes. Em adição, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal prevê que a busca domiciliar não prescinde de mandado judicial, salvo nas hipóteses excepcionais, constitucionalmente previstas, dentre elas o caso de flagrante delito.

Como é cediço, o ato análogo ao tráfico de entorpecentes é crime permanente e, em caso de flagrante de crime dessa natureza é possível a realização de busca domiciliar sem mandado judicial. No caso em tela, os policiais ingressaram no imóvel depois de abordarem o acusado na via pública, que estava praticando a traficância, sendo que ele próprio indicou o local de sua residência.

Assim, uma vez configurada a situação de flagrância, era perfeitamente lícito aos policiais militares, incumbidos do combate à criminalidade, adentrar na casa onde a droga estava sendo fracionada.

Não se pode cogitar, por conseguinte, na ilicitude das provas obtidas, pois o momento consumativo do delito de traficância se prolonga no tempo. A respeito da prescindibilidade do mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, há sedimentada jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE nº 603.616/TO; Relator Ministro Gilmar Mendes). Não cabe aplicação do princípio da insignificância, para que considere excluída a tipicidade material na conduta do acusado, vez a conduta repreendida se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito nos autos, não havendo que se cogitar de irrelevante penal.

A lei de drogas tutela a saúde pública, por consequência constitucional da bem jurídica vida, conforme artigo 5º, caput, da Constituição Federal, este de maior relevância para a coletividade. É o que entende o Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e uso de

substância entorpecente pois se tratam de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade apreendida. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp1609752 / SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DEASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)" grifei. Comprovado o tráfico de drogas, descabe falar em desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

Dessa forma, é de rigor a condenação do acusado pelo delito dos artigos 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, como medida de justiça.

Passo à dosagem da pena.

I. Quanto ao delito do artigo 33 da Lei 11.343/06:

Favoráveis às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, vez que o réu não possui maus antecedentes assim, ao tráfico de entorpecentes fixo a pena base no mínimo legal em: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes da pena.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/6, para resultar em: 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Reputo inaplicável o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, já que o acusado possui outra condenação pelo mesmo crime, por fato anterior a este, demonstrando que já se dedica a atividade criminosa da traficância

A pena do réu deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Incabível qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como incabível o sursis.

O valor do dia multa será do mínimo legal (artigo 38, caput e parágrafos, da Lei de Tóxicos).

Atendendo ao disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, deixo de considerar o tempo que o acusado ficou preso para fins de fixação de regime de pena já que para eventual progressão de regime, além do tempo de pena cumprido é necessário bom comportamento carcerário, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Ante todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar LUCAS DA SILVA PEREIRA RG: 55.109.117-4, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, com valor unitário estipulado no piso, como incursos na sanção do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, porque já se encontra preso, e por maiores razões assim deve permanecer, quiçá a gravidade do crime pelo qual ora fora condenado, justificando-se as cautelas por medida da garantia da ordem pública. Expeça-se mandado de prisão.

Recebido eventual recurso promovido pela parte, extraia-se carta de guia provisória, em favor do réu à Vara das Execuções Criminais competente.

Transitada em julgado para as partes, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Avare, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA